

1500434-21.2021.8.26.0537

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Patrícia Helena Hehl Forjaz de Toledo

Comarca: Diadema

Foro: Foro de Diadema

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 25/06/2022

... havia dinheiro no bolso. Ele negou o tráfico. Retornaram com ele até o local onde o avistaram, e acharam a necessária onde ele havia escondido, e no interior da mesma estava o dinheiro e as drogas. Ele só disse que estava no lugar errado e na hora errada. Reconhece o réu e foi a primeira vez que o viu no local, ponto de tráfico já conhecido. Fez campana na travessa Orlando ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Diadema

Foro de Diadema

2ª Vara Criminal

Avenida Sete de Setembro, 399, Diadema-SP - cep 09912-010

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500434-21.2021.8.26.0537 - Controle nº 2021/000285

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2056541/2021 - 02º D.P. DIADEMA, 16477965 - 02º D.P. DIADEMA, 390/21/123 - 02º D.P. DIADEMA, 2056541 - 02º D.P. DIADEMA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Valdemir Pereira

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Patrícia Helena Hehl Forjaz de Toledo

Vistos.

VALDEMIR PEREIRA, qualificado às fls. 10 e 25/26, está sendo processado pela prática do crime tipificado no artigo 33, caput, da Lei 11.343/06, porque no dia 26 de fevereiro de 2021, por volta das 15h00, na Passagem do Progresso, altura do nº 150, Viela Cassia Eller, no bairro Vila Nogueira, nesta cidade de Diadema trazia com ele e guardava, para fins de entrega ao consumo de terceiros, 33 embalagens plásticas contendo 20,01g da droga cocaína e outras 33 embalagens plásticas contendo 65,2g da droga maconha, conforme auto de apreensão de fls. 23/24 e laudo de constatação provisória de fls. 17/19, agindo sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Convertida a prisão em flagrante em preventiva (fl.64/66) o réu constituiu advogado, que apresentou defesa inicial às fls.181/189. Não sendo hipótese de arquivamento, a denúncia foi recebida em 04/08/2021 (fl.173) e certificada a notificação e a citação positiva do Réu as fls.217/218.

Em audiência de instrução, debates e julgamento foram ouvidas as testemunhas arroladas tempestivamente pelo MP. Pela ordem, o d. Advogado reiterou pedido de que suas testemunhas fossem ouvidas, bem como de reconstituição dos fatos, com o que discordou a d. Promotora de Justiça, sendo os pedidos novamente indeferidos, quer por falta de indicação de suas imprescindibilidades, quer porque, como se verá adiante, os dois policiais afirmaram que o réu estava na viela Orlando Dias visualizando a parte de baixo da Vuela Cassia Eller , e quando o réu seguiu subindo na direção da viela do Progresso, o detiveram na Passagem Tião Carrero, de modo que essas travessas/vuelas constaram expressamente descritas na denúncia, a permitir a ampla defesa, tanto que o d. Advogado juntou fotos justamente desse local, e os policiais, advertidos das penas do falso testemunho, esclareceram bem onde estavam e para onde se dirigiram, com clareza, precisão e segurança, inclusive onde pararam para fazer campana, que dava para ver a outra viela, a despeito do d. Advogado insistir que não e, por isso, caso entenda estejam os policiais descumprindo com a verdade, pode solicitar apuração de eventual crime de falso testemunho, não havendo como se desmerecer ou afastar os relatos por ter entendimento diverso ou pela prova não lhe favorecer. Tanto que o local foi identificado nas fotos juntadas pela própria Defesa às fls. 182 e 183, onde se visualiza as duas vielas citadas, Cassia Eller e Orlando Dias, e a direção tomada pelo réu, subindo sentido Passagem do Progresso, esclarecendo assim os policiais ser possível avistar o réu de onde estavam com a viatura estacionada, como se vê inclusive um carro estacionado na foto juntada a indicar ser possível a entrada de veículos no local. Assim, entendi não haver necessidade de maiores esclarecimentos nem imprescindibilidade da realização de mais uma prova acerca do local dos fatos, sendo declarada encerrada a instrução processual, dado que rejeitado o rol intempestivo juntado pelo então Advogado, estando preclusa essa prova, até por não ser crível que o réu não tivesse mencionado à sua primeira Advogada acerca dos seus amigos Jorge e Jaime, donos de uma mecânica e de uma lanchonete/bar respectivamente, e com quem teria estado minutos antes da prisão, para que pudessem ser arrolados à tempo. Ressalto que o art. 396a, do CPP prevê o momento para a apresentação do rol testemunhal, sob pena de preclusão, caso contrário, em se aceitando sem a concordância ministerial, rol intempestivo, estaria a se ferir o princípio da isonomia e da paridade de armas. Não bastasse tudo isso, ainda tem-se contrariamente ao pedido de oitiva de novas testemunhas de defesa a quebra da incomunicabilidade entre elas, dado que estavam todas juntas, no escritório do Advogado do réu, participando da colheita da prova oral, e por isso tão pouco podem ser admitidas como testemunhas do juízo, seguindo-se então com os debates orais apenas por parte do MP, já que o d. Advogado requereu prazo para juntada de memoriais alegando não estar se sentindo bem, com o que não se opôs a Acusação (tudo em mídia digital). Contudo, o Advogado, ao juntar seus memoriais três meses após o término da instrução processual, juntou também um parecer técnico do local dos fatos, incluindo fotografias (fls. 289/295), ao arrepio do indeferimento proferido, pelo que não será considerado como prova, consoante as razões já exaradas. Desentranhe-se-a.

Em debates orais, o Órgão Ministerial requereu a procedência da ação por provadas autorias e materialidade delitivas. Pleiteou a fixação da pena base no mínimo legal, concordando com a redução da pena, mas não também por sua substituição pela pena restritiva de direitos, fixando-se regime prisional mais benéfico e perda do numerário apreendido (fl. 29).

Já o Advogado, em seus memoriais (fls. 282/288) reiterou seu entendimento pela oitiva de testemunhas de defesa, e no mérito pretendeu a absolvição de seu cliente ante a fragilidade probatória. Subsidiariamente, pediu que a pena fosse reduzida e substituída conforme previsto no art. 44 do CP, fixando-se regime aberto e recurso

em liberdade.

É o breve relatório.

Passo a fundamentar e decidir.

Ressalto, pela terceira vez, que o momento processual adequado a se requerer oitiva de testemunha é na defesa inicial, quanto mais estando o réu assistido por Advogado constituído, sob pena de preclusão dessa prova, a não ser que a parte contrária (no presente caso o Parquet) concorde, o que não ocorreu, de modo que pelo princípio da isonomia as testemunhas de defesa arroladas intempestivamente não podem ser ouvidas, menos ainda nesse processo, porque não respeitada a incomunicabilidade entre elas. E quanto ao parecer técnico do local juntado pela Defesa, prova esta também indeferida em audiência, não será acolhida. Desentranhe-se-a.

No mérito, a ação procede.

A materialidade delitiva vem estampada no auto de exibição e apreensão de fls. 23/24, nos autos de constatação e no definitivo (fls. 17/19 e 271/273), ambos positivos para as drogas maconha e cocaína.

A autoria é inconteste não só com fulcro na prova amealhada extrajudicialmente, como na colhida sob o manto do contraditório que corrobora aquela e a qual passo a expor.

Segundo narrativas administrativas dos policiais civis (fls. 07/09), em apuração a uma denúncia anônima de tráfico de drogas na Viela Cássia Eller, onde um indivíduo de cútis parda, careca, trajando uma camiseta de cor preta, bermuda jeans e chinelo, estaria comercializando drogas, local este conhecido notoriamente como ponto de venda de drogas. Em virtude dos fatos, diligenciaram até o local em uma viatura descaracterizada, onde passaram observar à distância a dinâmica do tráfico de drogas. O indiciado encontrava-se parado na referida Viela. Durante a campanha perceberam que o indiciado escondeu uma bolsa preta entre uns arbustos, afastando-se um pouco do local, seguindo pela Passagem do Progresso, momento em que foram ao seu encalço e procederam a abordagem e a busca pessoal. Nada de ilícito foi localizado em seu poder, e ele negou que estaria traficando naquele local. Em seguida diligenciaram até os arbustos onde localizaram uma bolsa preta contendo em seu interior 21 porções de maconha, 33 porções de cocaína todas embaladas e individualizadas prontas para serem vendidas.

Sob o crivo do contraditório o policial Álvaro Malagutti Jr. respondeu que seu parceiro Cleber recebeu denúncia dando as características físicas e de vestes e que estaria na prática do tráfico de entorpecentes. Foram até o local indicado, Viela Cassia Eller. Fizeram campanha por uns quinze minutos numa viatura descaracterizada e com issofilm. Avistaram ao réu com uma nécessaire preta em mãos. E depois ele a escondeu atrás de umas plantas. Foi abordado na Travessa Tião Carrero e com ele havia dinheiro no bolso. Ele negou o tráfico. Retornaram com ele até o local onde o avistaram, e acharam a nécessaire onde ele havia escondido, e no interior da mesma estava o dinheiro e as drogas. Ele só disse que estava no lugar errado e na hora errada. Reconhece o réu e foi a primeira vez que o viu no local, ponto de tráfico já conhecido. Fez campanha na travessa Orlando Dias e viu o réu na travessa Cassia Eller na parte de baixo, e quando ele subiu foi que resolveram segui-lo e o prenderam na travessa Tião Carrero.

O policial Cleber Matias reiterou ter recebido uma denúncia anônima em que o denunciante informava a Travessa Cassia Eller e que o traficante estaria trajando determinada roupa. Foram até lá, pararam a viatura descaracterizada na travessa Orlando Dias, de frente para a travessa Cassia Eller. Fizeram campanha de uns dez minutos e viram o réu lá. Depois ele escondeu uma pochete atrás de umas plantas, e

subiu a viela, uma escadaria. Desembarcaram da viatura e o seguiram. O abordaram de costas. Revistado, havia cinco reais com ele. Desceram a viela até os vasos de plantas e ali localizou a mesma bolsa no local que o viu colocar ali. O réu disse que não era dele e que estava lá só para tomar uma cerveja, mas no tempo de campana, ele não tomou nenhuma cerveja. Dentro da bolsa estavam os entorpecentes. O dinheiro estava no bolso das vestes do réu. Reconhece o réu e não o viu naquela biqueira antes. Durante o tempo de campana não viram o réu vendendo algo a um usuário nem recebendo dinheiro, ou seja, em atos de venda. Mostrada a foto juntada a fl. 182, não foi nesse local que os fatos se deram até porque ali não dá para fazer campana de viatura parada e sim na foto de fl. 183, onde se vê um carro parado e onde pararam a viatura descaracterizada, na Passagem Orlando Dias em frente à viela Cassia Eller e dali visualizou o réu e daí ele subiu em direção à Travessa do Progresso. E a foto de fl. 185 não é local dos fatos.

O réu, em solo policial (fl.10) respondeu que se encontrava no local dos fatos, somente bebendo uma cerveja, bem como afirmou ''ESTAR NO LOCAL E NA HORA ERRADA''. Acrescentou não ser usuário de drogas, não residir pelo local da prisão, tendo ido somente para beber uma cerveja.

Em juízo o acusado alegou que não estava em poder de nada. Foi levar uma marmita para a sobrinha por volta das 14:30 hs. Pegou dez reais emprestado com o mecânico Jorge e tomou uma cerveja no bar do Sr. Jaime. Conhece essas pessoas por frequentar o local e dedetizar os comércios deles. Foi abordado na Av. Orlando Dias. Os cinco reais apreendidos consigo foi o troco da cerveja Skol. Não correu porque tem o joelho quebrado e não pode correr. Estava indo para casa e conhece o local há quarenta anos. Tem empresa de Detetização e não usa drogas. E não tem pé de planta no escadão. Há vinte e cinco anos atrás foi processado por roubo.

Contudo, se verdadeira fosse a versão trazida pelo réu em juízo, de que estaria no local apenas para tomar uma cerveja no bar do Jaime depois de ter pego emprestado dinheiro com o Jorge, o normal e correto seria ele já ter trazido essa versão desde solo extrajudicial, quando optou por afirmar estar "no lugar e hora errada", o que já tinha sido dito aos policiais, assim que detido. E mais, se havia levado uma marmita para sua sobrinha, já deveria tê-la arrolado como sua testemunha, assim como o mecânico e o dono do bar com quem disse ter tido contado pouco antes de sua prisão a indicar que não estaria traficando no local. E mesmo assistido por Advogado particular, nenhuma dessas pessoas, parente e conhecidos seus foram sequer arrolados, a indicar que essa versão tardia tenha sido arquitetada depois que o réu teve tempo e condições de amadurecer versão mais satisfatória aos interesses da nova defesa.

Logo, os depoimentos dos testemunhos - que são válidos e eficazes para a convicção condenatória, até por não haver dúvidas sobre sua lisura - estão em consonância com os demais elementos probatórios contidos nos autos, inclusive as fotos trazidas pela Defesa e mostradas aos policiais em audiência, quando ambos reiteraram terem estacionado a viatura descaracterizada na Travessa/Viela Orlando Dias, onde fizeram uma campana de aproximadamente dez a quinze minutos, e puderam visualizar o réu (por eles reconhecido) na Travessa Cássia Eller, onde fica o ponto de venda de drogas já conhecido e cuja denúncia anônima apontou como sendo o local onde um indivíduos cujas características físicas e de vestes estaria traficando. Tanto que ao chegarem no local e reconhecerem o réu, ainda o viram guardando algo num arbusto, num vaso, numas plantas, e acabaram por detê-lo na Travessa/Passagem Tião Carrero, estando ele em poder de dinheiro cuja procedência lícita, ou seja, emprestada do seu conhecido Jorge, não conseguiu demonstrar, tanto que não negou o crime aos policiais, pelo contrário, disse-lhes estar no lugar errado na hora errada. E some-se a isso o auto de apreensão e exibição das drogas diversas em quantidade razoável a indicar se destinarem à venda, além das provas periciais apontando para as substâncias cocaína e maconha, tudo sem prova contrária, até porque a versão extrajudicial do réu está dissonante de sua narrativa judicial.

Ressalto, por fim, ser cediço que no crime de tráfico de drogas, em regra, a prova é baseada nos depoimentos dos policiais. A defesa não apresentou nenhuma prova concreta capaz de ilidir as declarações dos policiais militares, não havendo motivo plausível para seu desmerecimento, consoante Enunciado 70 da Súmula de Jurisprudência do STJ. Ora: o valor do depoimento testemunhal de servidores policiais especialmente quando prestado em Juízo, sob a garantia do contraditório reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, de repressão penal. O depoimento testemunhal do agente policial somente não terá valor, quando se evidenciar que esse servidor do Estado, por revelar interesse particular na investigação penal, age facciosamente ou quando se demonstrar tal como ocorre com as demais testemunhas que suas declarações não encontram, suporte e nem se harmonizam com outros elementos probatórios idôneos (STF, HC 76.608-0).

Ainda que não presenciado qualquer ato de comércio, as circunstâncias do flagrante demonstram a conduta prevista no art. 33, caput, da Lei de Drogas, que consigna com o verbo nuclear guardar, conduta perpetrada pelo réu, comprovada a circulabilidade. O tráfico de drogas é crime de ação múltipla e a prática de um dos verbos contidos no art. 33, caput, é suficiente para a consumação da infração, sendo prescindível a realização de atos de venda do entorpecente. E no presente caso, ainda, tem-se a denúncia anônima informando não apenas o local da traficância como também as características físicas e de vestes do réu, que estava sozinho no local, e foi visto pelos policiais, durante campana, escondendo algo num vaso de planta e não numa área de vegetação, não conseguindo o réu demonstrar o que fazia no local, já que não mora nem trabalha lá, e embora tenha alegado estar apenas tomando uma cerveja, não comprovou, pois os policiais disseram que ele não estava tomando uma cerveja.

À luz do art. 28, § 2º, da Lei 11.343/06, a natureza da droga (cocaina), o local da prisão (um ponto de venda de drogas conhecido), o numerário apreendido (fl. 23/24), são fatores que, reunidos, permitem a conclusão indubitável de que o elemento subjetivo do agente dirigia-se especificamente à mercancia e não ao mero consumo pessoal, de modo que a procedência do pedido é inarredável.

Passa-se, pois, à dosimetria da pena.

Observado o art. 59 do Código Penal, os motivos, circunstâncias e consequências do delito a não demandar aumento inicial na pena, assim como a quantidade do narcótico apreendido que não reputo excessiva, às vistas do disposto no art. 42 da Lei de Drogas, fixo em primeira fase, a pena base mínima: 05 anos de reclusão e 500 dias-multa.

Em segunda fase, não há circunstâncias agravantes nem atenuantes a serem consideradas, restando a pena inalterada nessa etapa.

Em terceira etapa, não concorrem causas de aumento de pena. Quanto ao privilégio previsto no §4º, do art. 33, da Lei 11.343/06, o Réu faz jus ao beneplácito legal, porquanto seja primário (fls.99/101), donde a reduzo em 2/3, totalizando 01 ano e 08 meses de reclusão e 166 dias-multa, cada qual fixado em 1/30 do valor do salário mínimo atual tendo em conta ausência de elementos nos autos indicativos da capacidade financeira do Condenado.

O quantum da condenação, a primariedade do agente, a análise favorável das circunstâncias judiciais e a não excessividade de drogas, ausente o crack, a pior delas, permitem ao acusado iniciar o cumprimento da pena privativa de liberdade no regime aberto.

Contudo, incabível a benesse do art. 44 do CP, não se mostrando suficiente nem

eficaz à reprovação da conduta do agente, menos ainda socialmente recomendável sob pena de potencializar a sensação de insegurança e intranquilidade social, a merecer maior reprovabilidade a conduta, dado que viola mais intensamente o bem jurídico tutelado, somado ao elevado número de ocorrências de tal natureza conferindo constante desassossego à sociedade, a exigir firme repressão do Estado como forma de desestimular o crime, geralmente cometido graças ao nível de organização próprio daqueles que fazem do tráfico seu meio de vida.

Não bastasse isso, artigo 44, caput, da Lei de Drogas veda, expressamente, a substituição de pena privativa de liberdade por restritiva de direitos para o condenado pelos crimes previstos nos artigos 33, caput e parágrafo 1º, e 34 a 37. Já o artigo 33, parágrafo 4º, da Lei de Drogas, que prevê uma causa de diminuição de pena, também estabelece, no caso de sua aplicação, que a pena privativa de liberdade não poderá ser substituída por restritiva de direitos. Ainda, a 5ª Turma do Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de não ser possível a aludida substituição para o condenado por tráfico de drogas e condutas correlatas (artigos 33, caput e parágrafo 1º, e 34 a 37), bem como quando da aplicação da causa de diminuição de pena prevista no artigo 33, parágrafo 4º, da Lei de Drogas (HC 144.915/MG, Rel. Laurita Vaz, v.u., j. 01.06.2010. No mesmo sentido – STJ – HC 136.618/MG, 5ª t., Rel. Min. Laurita Vaz, v.u., j. 01.06.2010). ... Ora, não nos parece razoável proceder a substituição para autor de crime de suma gravidade. A personalidade, a conduta social e culpabilidade do traficante de drogas e de quem de qualquer forma o auxilia, bem como as consequências do crime, que são nefastas para o viciado e usuário e para a sociedade, não recomendam a substituição, que pode ser indeferida nos termos do artigo 44, III, do Código Penal. Ressalte-se, por fim, que a droga é o câncer que assola a todo o mundo já que, direta ou indiretamente, é responsável por boa parte dos crimes violentos que o afligem. Por causa dela as pessoas matam ou são mortas. É muito difícil um crime violento não ter a droga como estopim. Ou o agente está sob seu efeito, ou é vítima de um traficante ou de um drogado, ou é um traficante que mata um rival etc. Enfim, a droga, de uma maneira ou de outra, está ligada aos crimes mais graves.

Permito o recurso em liberdade diante do princípio da presunção de inocência, dado já estar o réu em liberdade, tendo comparecido a todos os atos processuais, donde me valho do princípio da presunção de inocência.

Por fim, não há valor mínimo de reparação do dano a ser arbitrado.

Dispositivo.

Posto isso, JULGO PROCEDENTE A PRESENTE AÇÃO contra VALDEMIR PEREIRA, qualificado às fls. 10 e 25/26, pela prática do crime tipificado no artigo 33, caput, da Lei 11.343/06, e o faço para condená-lo à pena de 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão, em regime aberto, mais ao pagamento de 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, cada qual fixado em 1/30 do valor do salário mínimo a época dos fatos.

Condeno o réu, ainda, ao pagamento das custas processuais, em 100 UFESPS, por ter constituído Advogado Particular.

O acusado poderá apelar em liberdade.

Decreto a perda de valores apreendidos nestes autos (fl.23), com fulcro no art. 63 da Lei 11.343/06.

Com o trânsito em julgado desta sentença, opere-se a detração penal, certifique-se e extraia-se a guia de recolhimento definitiva em relação à pena corporal, encaminhando-se à V.E.C. competente, certifique-se o cálculo da pena de multa.

Fica desde já autorizada a incineração dos entorpecentes e a destruição de objeto

apreendido (fls.23/24) .

Oficie-se ao Senad, ao IIRGD e TRE.

P.I.C.

Diadema, 25 de junho de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À
MARGEM DIREITA